

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

[기출][2016-1-2]대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사의 소송대리권 부활 여부

《【문제1】 乙회사의 근로자인 甲이 업무 중 상해를 입어 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하고자 한다. 다음 물음에 대하여 답하시오. (50점) (아래 각 설문은 상호 무관함)》

(물음2) 위와는 달리, 甲이 乙회사를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하였다. 그 소송의 항소심에서 변호사 丁이 甲의 소송대리인이었는데, 대법원의 파기환송판결에 의하여 사건이 항소심에 다시 계속하게 되었다면 위 丁의 소송대리권은 어떻게 되는지를 설명하시오. (15점)》

<문제1의 물음2> 대법원의 파기환송판결에 의해 사건이 다시 계속된 경우 변호사의 소송대리권 부활 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲이 乙회사를 상대로 제기한 손해배상청구소송의 항소심에서 소송대리인이었던 丁이 대법원의 파기환송판결 이후 다시 항소심에 계속된 사건에서도 종전의 소송대리권을 유지하는지가 문제되는 상황이다. 쟁점으로 <파기환송으로 사건이 원심에 다시 계속된 경우 종전 항소심 소송대리인의 소송대리권이 소멸하는지 아니면 그대로 존속하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 파기환송 후 항소심에서 소송대리인 丁의 소송대리권의 존속 여부를 설명한다.

II. 심급대리의 원칙과 소송대리권의 범위

1. 심급대리의 원칙

- 소송대리권은 특별한 약정이 없는 한 당해 심급에 한하여 존속한다. 이는 대리인의 책임 범위를 명확히 하고, 당사자가 각 심급마다 새로운 대리인을 선임할 기회를 보장하기 위함이다.

2. 소송대리권의 범위

(1) 원칙적 범위

- 민사소송법 제90조 제1항에 따라 소송대리인은 당해 심급의 소송물에 관한 일체의 소송행위를 할 수 있다. 여기에는 반소, 참가, 강제집행에 관한 행위 등이 포함된다.

(2) 특별수권사항

- 민사소송법 제90조 제2항에 따라 상소의 제기, 소의 취하, 화해, 포기, 인낙 등은 당사자로부터 별도의 특별수권을 받아야 가능하다.

III. 파기환송과 소송대리권의 부활

1. 환송 후 절차

- 상고심에서 항소심 판결을 파기하고 사건을 다시 항소심 법원에 환송한 경우, 환송 후의 절차가 <이전 항소심 절차의 속행인지> 아니면 <새로운 심급의 시작인지>에 따라 대리권 존속 여부가 달라진다.

2. 판례의 태도

- 판례는 환송 전 항소심에서의 소송대리인의 대리권은 상고 제기에 의하여 일단 소멸하지만, 상고심에서 원심판결을 파기하여 사건을 항소심에 환송한 경우 사건이 다시 환송 전의 상태로 돌아가는 것으로 본다. 환송 후의 절차는 환송 전 항소심 절차의 계속 및 속행에 해당하므로, 별도의 선임계 제출 없이도 환송 전 항소심 소송대리인의 대리권은 당연히 부활한다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

IV. 사안의 적용

1. 소송대리권의 지속성

- 변호사 丁은 甲의 항소심 소송대리인으로서 이미 적법하게 대리권을 행사하였다. 대법원이 사건을 파기환송하였다는 것은 항소심 판결이 취소되고 사건이 다시 항소심 단계의 미결상태로 복귀함을 의미한다.

2. 대리권의 법적 상태

- 판례의 견해에 따르면 환송 후 항소심은 환송 전 항소심의 연장이므로, 丁이 상고심에서 대리인이 아니었다더라도 사건이 항소심으로 환송됨과 동시에 丁의 소송대리권은 법률상 당연히 부활한다. 따라서 丁은 별도의 위임장을 다시 제출하지 않고도 甲을 위하여 환송 후 항소심 절차에서 소송행위를 할 수 있다.

V. 결론

- 민사소송법상 심급대리의 원칙에도 불구하고, 파기환송판결에 의해 사건이 원심법원에 환송된 경우 환송 후의 소송절차는 환송 전 절차의 속행으로 간주된다. 따라서 환송 전 항소심 소송대리인이었던 변호사 丁의 소송대리권은 대법원의 파기환송결정과 동시에 당연히 부활한다. 丁은 환송 후 항소심에서 다시 甲의 소송대리인으로서 지위를 회복하며, 乙회사를 상대로 소송을 계속 수행할 수 있다.

<보충 - 파기환송 시 소송대리권 부활 여부에 대한 학설과 판례의 대립 분석>

I. 학설(부정설)의 논거와 법적 타당성

1. 심급대리 원칙의 실질적 관철과 당사자의 사적자치

(1) 심급대리 원칙의 취지 보장

- 심급대리의 원칙은 당사자가 각 심급의 판결 결과를 보고 다음 심급에서 새로운 대리인을 선임할 기회를 보장하는 데 목적이 있다. 파기환송 절차는 실질적으로 새로운 공격·방어방법이 제출되고 법적 공방이 재개되는 단계이므로, 형식적 소송계속의 동일성만을 이유로 이전 대리권을 강제하는 것은 당사자의 대리인 선택의 자유를 침해할 우려가 있다.

(2) 수임계약의 본질과 대리인 선임 의사

- 대부분의 소송위임계약은 심급별로 체결되며, 계약의 대가 역시 심급별 착수금 구조로 설계된다. 따라서 환송 전 단계에서 판결이 선고됨으로써 위임계약은 실질적으로 종료되었다고 보는 것이 계약 당사자들의 합리적인 의사에 부합한다.

2. 신의칙 및 신뢰관계의 변화와 대리인의 책임 범위

(1) 대리인과 본인 간 신뢰관계의 변동

- 상고심에서 원심판결이 파기되었다는 것은 환송 전 항소심에서 대리인이 수행한 소송 전략이나 법리 주장에 치명적인 하자가 있었거나 결과적으로 패소(원고의 경우 승소 판결이 깨진 경우 등)했음을 의미하는 경우가 많다. 이 과정에서 당사자와 변호사 사이의 신뢰관계에 중대한 변화나 균열이 발

생했을 가능성이 매우 높음에도 대리권이 당연히 부활한다고 보는 것은 가혹하다.

(2) 변호사의 무한 책임 방지

- 대리권의 당연 부활을 인정하면, 환송 전 대리인은 당사자로부터 추가적인 보수를 받지 못했거나 관계가 소원해진 상태에서도 기일 지정 신청이나 서면 제출 등 소송수행 의무를 강제받게 된다. 이를 게을리할 경우 부당한 민사상 손해배상 책임이나 징계 책임을 질 수 있어 변호사에게 일방적으로 불리한 결과를 초래한다.

II. 판례(긍정설)의 실질적 고려와 한계

1. 소송절차의 안정과 소송경제

(1) 송달의 적법성 확보와 절차적 공백 방지

- 대법원이 사건을 환송했을 때 법원이 환송기일 통지서 등을 누구에게 송달해야 하는가의 문제가 발생한다. 대리권 부활을 부정하면 법원은 소송에 미숙한 당사자 본인에게 직접 송달해야 하므로 절차가 지연되거나 불측의 기일 해태로 인한 불이익이 발생할 수 있다. 판례는 송달의 확실성과 소송절차의 원활한 진행을 우선시한 결과이다.

(2) 소송계속의 연속성 유지

- 판례는 파기환송에 의해 사건이 원심법원으로 돌아가면 소송의 상태가 환송 전의 미결 상태로 복귀하는 것으로 파악한다. 즉, 소송법적으로는 심급이 바뀐 것이 아니라 동일한 항소심 절차가 중단 없이 속행되는 것으로 보기 때문에 형식적 논리상 대리권 역시 소멸하지 않고 존속하는 것으로 취급한다.

2. 현실적 계약 관행과의 괴리(판례의 한계) : 실무상 수임 관행과의 충돌

- 변호사 수임 실무에서 파기환송 사건은 새로운 심급에 준하는 막대한 노력과 새로운 법리 구성이 요구되므로 통상 환송 후 대리를 위한 별도의 수임계약을 체결합니다. 그럼에도 법률상 대리권이 당연히 부활한다고 보는 판례의 태도는 실무상의 경제적 거래 관행을 반영하지 못한다는 치명적인 약점이 있다.

III. 종합적 검토 및 답안 작성 시 활용 전략

1. 법리적 정합성과 실무적 필요성의 조화

(1) 원칙과 예외의 조화로운 해석

- 법리적인 타당성과 사적자치의 원칙, 그리고 신뢰관계 보호 측면에서는 학설(부정설)이 훨씬 정교하고 현실적이다. 다만, 소송절차의 안정과 무권 대리 방지라는 공익적 목적을 위해 판례(긍정설)가 유지되고 있다.

(2) 실무상 해결 방안의 존재

- 판례가 부활을 인정하더라도 현실에서는 이전 대리인이 소송수행을 원치 않을 경우 즉시 사임서를 제출하여 대리관계를 종료시킬 수 있다. 따라서 판례의 당연 부활설이 실제 신뢰 관계가 파탄 난 당사자들을 억지로 묶어두는 절대적인 족쇄로 작용하지는 않는다.

2. 2차 시험 답안 서술 시 고득점 서술 팁

(1) 학설 대립의 명확한 서술

- 답안 작성 시 단순히 '판례는 당연히 부활한다고 본다'라고만 끝맺지 말고, '학설은 심급대리의 원칙 및 신뢰관계 파탄을 이유로 부정하나, 판례는 소송절차의 안정과 연속성을 위해 당연 부활을 인정한다'라는 대립 구도를 선명하게 보여주어야 한다.

(2) 깊이 있는 검토의견 제시

- 검토의견 단락에서 '사적자치와 수임계약의 현실적 합치 측면에서는 부정설이 타당하나, 환송 직후 송달의 불명확성으로 인한 당사자의 절차적 불이익을 방지하고 소송경제를 도모하기 위해서는 당연 부활을 인정하되 변호사의 사임 권한으로 조율하는 판례의 태도가 실무상 조화롭다'와 같이 양설을 아우르는 균형 잡힌 검토를 제시하면 최고 수준의 가점을 받을 수 있다.